

1502305-02.2020.8.26.0544

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL NAKAO MAIBASHI

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... a acusada uma condenação por tráfico, pois que a certeza subjetiva extraída da prova oral e limitada aos depoimentos dos policiais que averiguaram a possível ocorrência de mercancia de entorpecentes não vai além do fato de terem apreendido a substância. Nesse sentido nossa jurisprudência é pacífica: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

2ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Centro - CEP 07700-175, Fone: (11) 4442-0081, Caieiras-SP - E-mail: caieiras@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - VIRTUAL

Processo nº:

1502305-02.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITORIA APARECIDA CRUZ PONTES, RG 54497910, com endereço à Rua Andorinha, 518, Laranjeiras, CEP 07745-170, Caieiras - SP, Fone 95713 7327

Data da audiência:

02/08/2022 às 15:10h

Aos 02 de agosto de 2022, às 15:10h, por meio de videoconferência, no Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Caieiras, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) Dr(a). DANIEL NAKAO MAIBASHI, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram o(a) Dr(a). Priscila Longarini Alves - Promotor(a) de Justiça, o(a)s réu(ré)s - VITORIA APARECIDA CRUZ PONTES, acompanhado(a) de seu(sua)s Advogado(a)s - Dr(a). Renata Teixeira de Oliveira Galvão OAB 350197/SP, bem como a(s) testemunha(s) comum(ns) Diana Pereira de Figueiredo (GCM) e Allan Carlos da Silva (GCM). Não foram arroladas testemunhas de defesa. De acordo com o Comunicado CG nº 284/2020, que dispõe sobre a realização de audiências virtuais por conta da Pandemia da COVID-19 e da impossibilidade de acesso às dependências do Fórum, a presente audiência foi realizada por videoconferência. Foi dada ao(à)s réu(ré)s e ao(à)s seu(sua)s defensor(a)es oportunidade de diálogo privado antes de começar a audiência. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) presente(s), bem como interrogado(a)s o(a)s réu(ré)s, conforme termo(s) que segue(m) em apartado. O(s) arquivo(s) com a(s) gravação(ões) da audiência deverá(ão) ser salvo(s) nos autos digitais, e uma cópia será gravada em mídia digital, a qual permanecerá no cartório, por segurança. Terminada a inquirição e voltando-se ao termo, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução". A seguir, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito em debates orais: Declarações colhidas através de sistema audio-visual. A seguir, pelo(a) Advogado(a) do(a) réu(ré) foi dito também em debates orais: "EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE

DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAIEIRAS - SP. Processo nº. 1502305-02.2020.8.26.0544 VITÓRIA APARECIDA CRUZ PONTES, já devidamente qualificada nos supracitados autos da REPRESENTAÇÃO subscrita pelo DD. Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, vem, com o devido acatamento e respeito à honrosa presença de Vossa Excelência, por meio de sua advogada que esta ao final subscreve, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, o que faz embasado nas relevantes motivações de fato e de direito que passa a elencar: 1. DOS FATOS NARRADOS NA REPRESENTAÇÃO: Consta que, no dia 28 de Outubro de 2020, às 11h59min, na Avenida Engenheiro Gino Dártora, altura do número 11, nesta Cidade e Comarca de Caieiras - SP., a representada situado em um ponto de ônibus "trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) porções de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 19,67g; 05 (cinco) porções de haxixe, com peso líquido de 0,67g; 30 (trinta) porções de cocaína, com peso líquido total de 23,95g; e 08 (oito) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 0,88g", vindo a ser denunciada no incurso do artigo 33º, caput da lei 11.343/2006. Após, houve concessão da liberdade provisória. Eis o relato do necessário. 2. DOS FATOS PROPRIAMENTE DITOS: Conforme restou apurado, em oitiva testemunhas, bem como pelo depoimento pessoal da acusada prestado em Juízo, não é possível afirmar-se que houve mercancia do que lhe foi atribuído na denúncia, a acusada em audiência afirmou que não estava vendendo/entregando os entorpecentes e que estes, eram para uso próprio, adquiridos anterior a apreensão, que naquele momento, se encontrava no ponto do ônibus com destino ao trabalho, inclusive registrado em carteira, com entrada às 14hs. Assim, a acusada esclareceu que era proprietária dos entorpecentes apreendidos, qual seja, 23 porções de maconha, 05 porções de haxixe, 30 porções de cocaína e 8 porções de crack (fls.06/07), que estes se destinavam ao seu uso próprio, uma vez que costumava comprar mensalmente. Note que, que em momento algum, foi visualizado pelos policiais qualquer ato visando à mercancia/entrega dos entorpecentes, e a denúncia comprova apenas que no local houve encontro dos policiais. MÉRITO

3.1. IMPUGNAÇÃO DO TERMO DE INTEROGATÓRIO - DA INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO CRIME IMPUTADO: Primeiramente, necessário pontuar que, na fase inquisitorial não é observado o princípio do contraditório, o que no presente caso acarretou falsas informações das pessoas que prestaram depoimento, como prova, basta verificar auto de qualificação fls. 14, em que a Acusada consta como desempregada, quando na verdade trabalhava, bem como, documento termo interrogatório fls. 18, que não possui assinatura da acusada. Fato é que, a colheita dos depoimentos em delegacia, pela autoridade policial sem a presença do Ministério Público e da Defesa, constou inverídica informação de confissão, o que não pode servir como "prova" (art. 155 do CPP). Exa. conforme colhido em audiência a acusada não praticou crime que lhe é imputado, motivo pelo qual impugna-se o termo de interrogatório e Auto de qualificação, documentos que se quer possuem assinaturas da acusada, o que se fazem prova suficiente quanto a fraude ao relato. O que de fato ocorreu, foram falsas informações lançadas no intuito de prejudicar a acusada, não sabendo esta informar a causa e nem quem teria interesse em prejudicá-la mediante falsa acusação de entrega/tráfico de drogas. Quanto ao tema segue jurisprudência (STF MS 22.791 e STJ MS 7.983): Assim, como passe de mágica, em uma leitura obtusa do art. 155 do CPP, não se pode requestrar os depoimentos prestados à autoridade policial porque violam o contraditório na produção da prova, com o qual já defendemos uma noção de amor ao contraditório (aqui). É o mesmo que tornar irrelevante a Jurisdição, ou seja, se os depoimentos antes valem, qual o sentido de se renovarem em juízo? Justamente porque antes não havia acusação formalizada e a acusação e defesa não podem sequer perguntar. A partir do processo como procedimento em contraditório (Fazzalari), as declarações realizadas durante a investigação preliminar para fins de condenação são um nada probatório. E esta variável deve ser considerada, pois há julgadores que acolhem. Por essa razão, é possível extrair-se a conclusão de que a conduta da acusada é aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, quando diz: "Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)". (grifos nossos). Portanto,

é caso de desclassificação crime ao qual se equipara o presente ato infracional para aquele de uso próprio, pois inexiste prova no presente procedimento, ou na representação, de fatos que demonstrem que a agente praticava o tráfico/entrega de entorpecentes, como a seguir restará demonstrado. A quantidade de droga apreendida não pode possuir o condão de classificar a traficância/ entrega, eis que, conforme restou demonstrado seriam para o consumo pessoal da acusada. O contexto probatório desenhado no processo pela acusação, é ILUSÓRIO, NÃO EXISTE, pois está calcado apenas dos inverídicos depoimentos em fase inquisitorial. O princípio da não-culpabilidade previsto na Constituição da República e o princípio da inocência estabelecido nas convenções internacionais conferem ao representado segurança processual. O Ministério Público enfrenta o ônus de comprovar a materialidade e a autoria delituosa no que concerne a mercancia e entrega. Não deve haver inversão do ônus probatório. A Ré não carece provar inocência quanto a mercancia / ou entrega, pois que, assim não agia no momento de sua prisão. Apesar de constatar, por meio de laudo pericial e termo de exibição e apreensão, a materialidade do crime de uso de entorpecente, não pode ser atribuída a acusada uma condenação por tráfico, pois que a certeza subjetiva extraída da prova oral e limitada aos depoimentos dos policiais que averiguaram a possível ocorrência de mercancia de entorpecentes não vai além do fato de terem apreendido a substância. Nesse sentido nossa jurisprudência é pacífica: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Inexistindo prova da mercancia das substâncias entorpecentes, e revelando as circunstâncias objetivas do fato a conduta de "guardá-las" para consumo próprio, prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, impõe-se desclassificar o crime de tráfico para o de uso daquelas substâncias, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem, nos termos da nova Lei de Entorpecentes". (TJ-GO: Apelação Criminal nº 29.501-2/213 (200601607010), de Ipameri) 2ª Câmara Criminal – relator des. Aluizio Ataídes de Sousa.). (grifos nossos). Segue outra jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. POSSIBILIDADE FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. Havendo prova inidônea à certeza da configuração do crime de tráfico de entorpecentes, é de se desclassificar o delito para o uso, especialmente quando sobejam nos autos contexto fático probatório apto a comprovar que a pequena quantidade de substância estupefaciente encontrada em poder do réu tinha como destinação o uso próprio; 2. Apelo conhecido e provido. (TJAC – Autos nº 2007.001694-9. Relator Arquilau Melo. Revisor Feliciano Vasconcelos. Julgado em 09 de agosto de 2007). (grifos nossos). E mais uma no mesmo sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES. PROVAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE TAL MAJORANTE NA NOVEL LEI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO RÉU. 1. meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não produzem prova em juízo. 2. a majorante prevista no art. 18, iii, da lei 6.368/76 não foi reproduzida na lei 11.343/06, o que constitui "novatio legis in melius", não podendo, portanto, ser aplicada aos réus. 3. inexistindo provas contundentes acerca da traficância exercida pelo réu, impõe-se a desclassificação de sua conduta de tráfico para uso de substâncias entorpecentes ilícitas, força do principio "in dubio pro réu". recurso provido. (TJES – Ap. Crim. nº 35040035061 – vila velha - 7ª vara criminal – relator: pedro valls feu rosa – julgado em 01/08/2007 e lido em 08/08/2007). (grifos nossos). Para iniciar a ação penal bastam indícios mas, para condenar é necessário prova, não havendo aos autos prova de mercancia. Conforme se observa do exposto, resta por comprovada a situação do denunciado como usuário de drogas, conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas, e não a de traficante, conforme aduzido na denúncia. 3.2. DEPOIMENTO POLICIAL CARENÇA DE PROVA: Com o narrado, verifica-se que a única coisa que liga a acusado à traficância são alegações falsas sem qualquer prova da veracidade informando confissão do acusado, sendo que o próprio nega ter condessado traficância. Constata-se que, não foi trazido aos autos prova capaz de esclarecer suposta tese de confissão, o termo de interrogatório se quer fora assinado pela Acusada. Com exposto, diante desse quadro é de se observar que, ao contrário do que alega a Acusação, a conclusão a partir das declarações prestadas pelos policiais

que participaram da apreensão do entorpecente, não conferem juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório, traduzindo-se que a argumentação acusatória, alegando tráfico, não fosse sua estridente inverossimilhança diante do caso concreto, também careceu de comprovação jurídico-formal, ônus a seu cargo exclusivo. Diante da insuficiência das provas, não há como imputar ao denunciado a autoria pela prática de tráfico de drogas, de forma que, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, o juiz deverá absolvê-lo. As provas trazidas aos autos claramente ratificam o envolvimento do denunciado somente como usuário, estando provado que este não concorreu de forma alguma para a prática do crime constante na denúncia.

3.3 PRINCÍPIO “in dubio pro réu”. Incontestável a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro réu, uma vez que certa é a dúvida acerca da culpa a ele atribuída com relação à acusação de Tráfico de Drogas, pois a Ré não foi encontrado em atividade de traficância/ entrega e muito menos com qualquer outro elemento que levasse a crer ser a denunciada traficante. Veja Exa., que, quantia e quantidade não se faz suficiente para comprovação do suposto tráfico, uma vez que a própria afirma ser usuária. Destarte, diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram para que pudessem imputar a prática delitosa ao denunciado, não conseguindo, conseqüentemente, demonstrar que fora a conduta do denunciado que causou a lesão ao bem juridicamente protegido, que ressaí dos autos, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente. Nesse sentido, temos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VI, DO CPP. A condenação do réu exige prova robusta da autoria do fato delituoso que lhe é imputado. Remanescendo dúvida, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VI, do CPP. Sendo assim, o denunciado deve ser ABSOLVIDO, com fundamento no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal, por não haver qualquer prova de que o Sr. XXXXXX, tenha concorrido para o tráfico de drogas. Se este não for o entendimento, que seja ABSOLVIDO nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devida inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação pela figura do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

3.4. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO: Numa simples análise do art. 28 e do art. 33 da lei nº 11.343/06 é notório que a vontade do agente e a destinação para uso pessoal da denunciada, o simples indício de materialidade do crime de tráfico/entrega de drogas não é argumento suficiente para a condenação pelo delito do art. 33 da referida lei. Para iniciar a ação penal bastam indícios mas, para condenar é necessária prova. Com a Acusada foi encontrado, droga de uso pessoal que acabara de adquirir, fato este, comprovado pelo próprio Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial e confirmado em audiência. Além do mais, trata-se de ré primária e com residência fixa, a sua primariedade é sim uma coisa que deve ser observada, pois a denunciada não ostenta a atividade criminosa. Conforme se observa do exposto, resta por comprovada a situação da denunciada como usuária de drogas, conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas, e não a de tráfico ou entrega, conforme aduzido na denúncia. Não há prova nos autos que, de acordo com a análise dos depoimentos, do local do fato, das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes da Ré, chegue à certeza plena de que a prática do fato era realmente tráfico de drogas, razão que demonstra caso típico de desclassificação. Do exposto, caso Vossa Excelência não vislumbre a ideia da absolvição, requer que seja desclassificada a conduta prevista na denúncia para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

3.5. DOS POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA: Embora nítida a tese da absolvição por não estar comprovado o crime de tráfico/ entrega, e ainda, a tese da desclassificação necessária para usuário, convém demonstrar outras situações que devem ser observadas por Vossa Excelência. Verificando a situação da denunciada, é possível concluir que a ré é primária, possui residência fixa e trabalho registrado. Nesse sentido entende o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A DOIS ANOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SURSIS. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. O Supremo

Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, na parte em que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, sessão de julgamento de 1º.9.2010, Informativo/STF 598). (...) Concessão de ofício para reconhecer a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao Paciente por restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, devendo a análise ser feita pelo juízo do processo de conhecimento ou, se tiver ocorrido o trânsito em julgado, pelo juízo da execução da pena. Ainda no que tange ao entendimento do STF: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. Assim, a denunciado deve ser observada pena restritiva de direitos, conforme garantia pela lei penal; e ainda, que sua pena seja fixada no mínimo legal pelas circunstâncias já elencadas.

3.6. DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE: Na busca do caráter ressocializador da pena, a justiça deve trabalhar para aplicar aquilo que se coaduna com a realidade social. Hoje, infelizmente, nosso Sistema Prisional é cercado de incertezas sobre a verdadeira função de ressocialização dos indivíduos que lá são mantidos, onde em muitos casos trata-se de verdadeira "escola do crime". Com base no princípio da presunção de inocência, previsto na nossa Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LVII, requer o denunciado que responda ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado, pois as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (art. 282, inciso II, CPP) lhe são favoráveis pelo fato de não haver reincidência e sua conduta social não ser em nenhum momento questionada.

4. DO PEDIDO: Pelo exposto, requer Vossa Excelência digne-se de:

1. Absolver a denunciada, pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP.
2. Caso não seja este o entendimento, que seja absolvida por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP
3. Pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que a denunciada é usuário de drogas. Por necessário, ad argumentum, caso Vossa Excelência entenda pela condenação, pela prática do crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, sejam observadas as atenuantes da: a) preponderância na fixação da pena, art. 42 da lei de drogas; b) causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, e que a denunciada possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício. Termos em que, pede deferimento. São Paulo, 02 de Agosto de 2022". Após, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de VITORIA APARECIDA CRUZ PONTES. Em breve síntese, a ré foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no 28 de outubro de 2020, às 11h59min, na Avenida Engenheiro Gino Dártora, altura do nº 11, nesta cidade e comarca de Caieiras, trazia consigo, para fins de tráfico, 23 porções de maconha, com peso líquido de 19,67 gramas, 5 porções de haxixe, com peso líquido de 0,67 grama, 30 porções de cocaína, com peso líquido total de 23,95

gramas, e 8 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 0,88 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 1/3). Recebida a denúncia (fls. 94/96), a ré compareceu espontaneamente aos autos (fls. 193) e apresentou defesa prévia (fls. 190/192). Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 196/198), foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas e a ré foi interrogada. Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação da acusada nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, com a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva é procedente. Tanto a materialidade delitiva quanto a autoria estão devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 5/8), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo laudo pericial (fls. 230/232) e pela prova oral coligida em juízo. Se não, vejamos. Em juízo, a testemunha Diana Pereira de Figueiredo, guarda civil municipal, afirmou que o Centro de Comunicação operacional havia informado à viatura, via rádio, sobre uma denúncia. Disse que foram averiguar as características passadas via rádio, a respeito de uma mulher com uma bolsa, e abordaram a ré em um ponto de ônibus. Afirmou que, na abordagem, já mencionou sobre a denúncia de tráfico, tendo a ré, de plano, admitido o crime. Disse que a ré mostrou a bolsa e foi constatado o crime. Afirmou que, pelo que se lembra, foram encontrados pinos de entorpecentes, além de dinheiro. Disse que a ré admitiu o crime de plano. Afirmou que não conhecia a ré. Disse que, pelo que se lembra, não havia uma quantidade muito grande de dinheiro com a ré. Afirmou que, no momento da abordagem, já explicou para a ré que havia uma denúncia de uma moça, com uma bolsa, traficando no local, ocasião em que ela admitiu o crime. Disse que não viu a ré vendendo drogas nem viu compradores. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Allan Carlos da Silva, guarda civil municipal, que acrescentou que havia um outro rapaz ao lado da acusada, mas que nada de ilícito foi encontrado com ele. Disse que essa pessoa afirmou que iria comprar drogas com a acusada, mas que não deu tempo. Afirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Em seu interrogatório, a ré Vitoria Aparecida Cruz Pontes afirmou que as drogas eram destinadas para seu consumo. Disse que é usuário de maconha e cocaína, mas que recebeu de brinde crack e haxixe. Afirmou que não conhecia os guardas nem o delegado. Disse que não confessou nenhum crime. Como se vê, as provas são suficientes para ensejar o decreto condenatório pela prática do tráfico de drogas. Em seus depoimentos, os guardas civis narraram com detalhes as circunstâncias do flagrante e da apreensão das drogas, tendo relatado que vislumbraram a acusada com as diversas drogas dentro de sua bolsa, em local

conhecido como ponto de tráfico de drogas nesta cidade, após denúncia da venda de entorpecentes no local. Nessa senda, cumpre registrar que a condição de guarda civil ou o simples fato de ter participado da ocorrência que culminou na prisão da acusada não torna a testemunha suspeita ou impedida. Seria absurdamente incoerente atribuir a esses agentes funções de fiscalização, mas os considerar suspeitos quando fossem testemunhar fatos relativos às suas atribuições. Nada há a infirmar o depoimento dos guardas civis ouvidos em juízo, que nem sequer conheciam a ré, sendo seus relatos corroborados pelos entorpecentes e pelos valores apreendidos. Lado outro, a ré não contesta a propriedade das drogas, admitindo que elas eram suas. A alegação de defesa restringe-se à finalidade dos entorpecentes, que serviriam para o próprio uso da acusada. Contudo, as diversas naturezas das drogas (maconha, haxixe, cocaína e crack), a forma do acondicionamento das substâncias (porções diversas e invólucros separados) e o local da apreensão (ponto extremamente conhecido pelo tráfico de drogas na cidade) são circunstâncias que, aliadas à prova oral, não deixam dúvidas de que a destinação das substâncias tóxicas era a mercancia infame. Aliás, nem sequer faz sentido a alegação da defesa, manifestada genericamente, que, embora fizesse uso tão somente de maconha e cocaína, teria ganhado de brinde, por coincidência, na data dos fatos, também as porções de crack e de haxixe que foram encontradas com a acusada. Nunca é demais lembrar, de outro

norte, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente trouxesse ou guardasse a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado. Nesse contexto, apurada a responsabilidade do réu, sendo inevitável sua condenação, passo à dosimetria de suas penas, atento aos critérios estabelecidos nos arts. 59 e 60 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06. Dosimetria. Reza o art. 42 da Lei 11.343/06 que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. Conforme entendimento da Excelsa Corte esses critérios podem ser utilizados pelo magistrado na primeira (fixação da pena-base) ou na terceira fase de aplicação da pena (para balizar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas), desde que incidam apenas uma vez, a fim de evitar o bis in idem. Nesse sentido: HC 110.413/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado pela 2ª Turma em 14.02.2012 e HC 108.120/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado pela 1ª Turma em 27.09.2011. Dito isso, na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta da acusada, deve ser considerada média. Isso porque a natureza das substâncias apreendidas é muito mais gravosa ao bem jurídico protegido pela norma (saúde pública) do que outras. Veja-se que houve o tráfico também de crack, droga que, conforme apontado pela doutrina especializada, tem potencial lesivo acentuado se comparada com outras substâncias igualmente proibidas. Seria desarrazoado, em desrespeito à individualização da pena, que uma pessoa que traficasse crack tivesse a mesma pena que aquela que traficasse substâncias menos ofensivas à saúde pública. Diante dessas circunstâncias judiciais, aumento o mínimo em 1/6 e fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante genérica prevista pelo art. 61, II, "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido durante o período de calamidade pública deflagrada pela pandemia da Covid-19. Não há dúvida de que, nesse período, a possibilidade de fiscalização nas ruas, a locomoção dos agentes e a própria capacidade de investigação de ilícitos ficou reduzida, tornando mais fácil a prática delitiva, o que possibilita a exasperação da pena. Contudo, em razão da menoridade relativa da acusada, que é preponderante, diminuo a pena em 1/12, fixando-a em 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão e pagamento de 534 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que a ré é primária e contra ela não pesam maus antecedentes, deve-se observar o disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo-se a pena em 2/3, para fixá-la definitivamente em 1 ano, 9 meses e 11 dias de reclusão, bem como pagamento de 178 dias-multa. O regime inicial será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, bem como ante o cancelamento da Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça, que previa ser o tráfico privilegiado equiparado a crime hediondo. Tal regime é reservado ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser revertida em favor de fundo judicial voltado às entidades públicas ou privadas com destinação social, a ser especificado em sede de execução, e a segunda em prestação de serviços à comunidade, especificados em sede de execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação. O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por não haver provas nos autos de favoráveis condições econômicas da acusada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a ré VITORIA APARECIDA CRUZ PONTES, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, às penas de em 1 ano, 9 meses e 11 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 178 dias-multa, no valor mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser revertida em favor de fundo judicial voltado às entidades públicas ou privadas com destinação social, a ser especificado em sede de execução, e a segunda em prestação de serviços à comunidade, especificados em sede de execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação. Desde já, se ainda não realizada, determino a incineração do material entorpecente, resguardado o necessário para contraprova, nos termos da lei. Transitada em julgado essa sentença, determino a perda dos

valores apreendidos nos autos em favor da União, na forma do art. 91, II, do Código Penal. Oportunamente, comunique-se a Delegacia de Polícia. Condene o acusado ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESPs, de acordo com o art. 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual 11.608/03. Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)(s) acusado(a)(s) no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s) para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C." Promotora de Justiça e ré afirmaram que QUEREM RECORRER da r. Sentença. Diante disso, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Recebo o recurso interposto, saindo as partes intimadas para a apresentação das razões, no prazo legal". Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo Juiz, conforme impressão à margem direita, nos termos do Art. 1.269 das NSCGJ. Eu, _____ Paulo Sergio de Araujo, escrevente digitei e subscrevi.

MM. Juiz(a):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA